

1514673-84.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FELIPE GERVASIO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

FELIPE GERVASIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 15 de junho de 2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1514673-84.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514673-84.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FELIPE GERVASIO DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

FELIPE GERVASIO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 15 de junho de 2021, por volta das 6h30, na altura do número 174 da rua Nandiras, em Perus, nesta cidade e Comarca, entregue ao adolescente V.O. 56,8 gramas de cocaína, distribuídos em 131 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para consumo alheio.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 41/45).

A denúncia foi oferecida às fls. 58/60.

Determinou-se a citação e notificação do réu.

O réu foi regularmente citado (fls. 107), apresentando Defesa Prévia por meio de Defensor Constituído que formulou pedido de concessão de liberdade provisória, que foi deferido por este Juízo, por ocasião do recebimento da denúncia e da designação de audiência de instrução, debates e julgamento.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos das testemunhas, os policiais Juliano Aparecido Barbosa e Jonatas Virgem da Silva, da testemunha arrolada pela Defesa Reinaldo Campos. Ausentes as outras testemunhas arroladas pela Defesa e, diante da insistência na oitiva, designou-se nova data.

Na nova data designada, as testemunhas faltantes não foram localizadas, assim como o réu não foi interrogado em razão de sua revelia.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia vez que comprovada autoria e materialidade delitiva a partir da prova oral e documental coligida aos autos. Quanto à dosimetria da pena, requereu sua fixação acima do quantum legal haja vista a significativa quantidade de substâncias entorpecentes em poder do acusado (131 porções de cocaína), além do envolvimento de adolescente no comércio ilegal de drogas; requereu também a não aplicação do redutor legal e, por fim, fixação de regime prisional mais gravoso.

Já, a Defesa, invocando os princípios constitucionais da garantia a ampla defesa e da presunção de inocência, pugnou pela absolvição do réu por falta de provas concludentes para sua condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mesmo porque os policiais apresentaram versões contraditórias em Juízo e, durante a etapa policial. De forma subsidiária, requereu também a desclassificação para o crime tipificado no artigo 28, da Lei nº 11.343/2.006 e; por fim, em caso de condenação, requereu aplicação do redutor legal em seu patamar máximo, afastamento das disposições do artigo 40 e incisos, da Lei nº 11.343/2.006, vez que não cabalmente comprovado o envolvimento do menor na traficância, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além do direito de apelar em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia. Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/07), auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição/apreensão (fls. 18/19), laudo de constatação (fls. 20/23), laudo pericial definitivo (fls. 67/69) além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, a despeito da revelia do réu em Juízo. Vejamos.

O réu, na fase policial, negou todos os fatos, aduzindo ser usuário de cocaína, nem como negou estar em posse da sacola com os entorpecentes (fls. 13).

Em Juízo, apesar de regularmente intimado, deixou de comparecer em audiência de instrução, debates e julgamento, decretando-se sua revelia.

Contudo, apesar de sua revelia, as demais provas coligidas aos autos demonstram à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

A testemunha policial militar JULIANO APARECIDO BARBOSA, em fase policial (fls. 08), relatou que, na data dos fatos, "realizavam patrulhamento de rotina pela região conhecida pelo tráfico (Recanto dos Humildes), momento em que do alto observaram um movimento aparente de traficância ocorrendo em uma viela logo abaixo.

Disse que, visualizaram o indivíduo identificado como Reinaldo Campos, o qual observava o movimento na rua, quando chegou FELIPE, o qual apresentava um volume em sua cintura, bem como se aproximou o adolescente VINICIUS. Alega que, desceram até a viela para realizar a abordagem, quando se depararam com FELIPE transferindo de sua cintura uma sacola plástica para ser entregue a VINICIUS, a qual continha diversos pinos de cocaína e outros invólucros plásticos contendo a mesma substância. Informa que, em revista pessoal foi encontrado com o adolescente VINICIUS a quantia em dinheiro de R\$40,00 (quarenta reais) em notas fracionadas e um papel contendo anotações, enquanto com FELIPE foi apreendida a sacola plástica contendo as substâncias ilícitas, já com Reinaldo nada de ilícito foi encontrado. Disse que, indagados os capturados acerca da conduta, Felipe e Reinaldo negaram a prática do crime, enquanto o adolescente assumiu que estava praticando tráfico e informou que Felipe é quem "abastece" a biqueira".

A testemunha, policial militar JONATAS VIRGEM DA SILVA, em fase policial (fls. 09), apresentou idêntico relato ao de seu colega de farda.

Os dois policiais ouvidos durante audiência, corroboraram, de forma cabal, a versão dos fatos apresentada durante a fase policial.

Com efeito, afirmaram que estava realizando patrulhamento de motocicleta pelo local dos fatos, quando avistaram três indivíduos, sendo certo que, a testemunha arrolada pela Defesa Reinaldo avisou ao adolescente Vinicius e ao réu Felipe que a Polícia Militar estava se aproximando. Ocorre que, como estavam com motocicletas, não houve tempo hábil para que os envolvidos empreendessem fuga do local dos fatos, apesar de terem tentado. No exato minuto em que foram surpreendidos, Felipe que segurava a sacola com as drogas em suas mãos e tentava entregá-la para o adolescente que, ao perceber a aproximação da polícia, se recusou a pegá-la e tentou fugir, sem obter êxito. Segundo lograram êxito em apurar no local dos fatos, o adolescente Vinicius realizava a venda dos entorpecentes no local (que já era conhecido da Polícia Militar) e, quando acabava, alguém sempre vinha abastecê-lo.

Com Felipe encontraram a sacola plástica com as drogas; com Vinicius a quantia de R\$40,00 em dinheiro, além de um papel com a contabilidade. O adolescente admitiu que já traficava no local há algum tempo.

A testemunha arrolada pela Defesa, de nome Reinaldo disse que é amigo do réu e, no dia dos fatos estavam bebendo cerveja, após um dia de trabalho, quando os policiais surgiram, que não havia nenhuma droga no local e, foram levados ao Distrito Policial. Nem droga, nem adolescente, no local.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para se duvidar do depoimento dos policiais, funcionários públicos, haja vista que não há qualquer indício que possa indicar que tivessem interesse em alterar a verdade dos fatos, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídos somente de interesse no esclarecimento da verdade.

E, quanto a eventuais pequenas contradições nos depoimentos policiais em Juízo e, durante a fase policial, ressalto que, tais contradições são normais, haja vista o lapso temporal decorrido entre a data da prisão em flagrante e a realização da audiência de instrução, bem como, diante do grande número de ocorrências similares. Frise-se que a versão apresentada pelo amigo do acusado (afirmou que estavam num bar bebendo cerveja juntos; que não havia nem adolescente, nem drogas no local), a testemunha arrolada pela Defesa, de nome Reinaldo, não pode prosperar, haja vista que não se coaduna com o restante da prova oral coligida aos autos. Além disso, por se tratar de pessoa amiga do réu e do adolescente que, inclusive, alertou a eles

acerca da chegada da Polícia Militar no dia dos fatos, seu depoimento deve ser encarado com sérias reservas, por não demonstrar a real expressão da verdade. O conjunto probatório é seguro e convincente, apesar da revelia do acusado, pela quantidade da droga apreendida, consistente em 56,8 gramas de cocaína, distribuídos em 131 porções de cocaína acondicionadas em pequenas embalagens de plástico, bem como pela quantia em dinheiro, em cédulas de pequeno valor, corroborado pela narrativa dos policiais que participaram da prisão do acusado, tudo devidamente ratificado em Juízo que, aliás, salientaram que, o local onde se deu abordagem já era conhecido da Polícia Militar por se tratar de local de tráfico de entorpecentes, assim como, o adolescente que estava na companhia do réu também já era conhecido.

Destaque-se, por oportuno, que a quantidade da droga apreendida não se presta ao reconhecimento do porte para uso próprio, visto que não se trata, em hipótese alguma, consoante ressaltado, de quantidade irrisória.

A quantidade e o modo de disposição das drogas (embaladas individualizadas) e as circunstâncias em que apreendidas, em ponto conhecido como sendo de tráfico de drogas, mostram-se compatíveis com destinação para o comércio ilícito, de que claramente proveniente o dinheiro apreendido.

Isto em conjunto com as demais provas amealhadas em regular instrução em juízo, denotam a incidência da conduta tipificada no artigo 33, caput da Lei 11.343/06. Quanto à tese defensiva de que o réu faria jus à causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, verifica-se que, de fato, é réu é primário, não possui maus antecedentes como se observa da folha de antecedentes (fls. 30/32) e certidão de (fls. 33).

Não há indícios, nos autos, de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.

Contudo, considerando-se que traficava elevada quantidade de drogas, com grande diversidade, especialmente, dentre outras, substância conhecida como "cocaína", que possui natureza altamente nociva, apta a gerar dependência com facilidade e agilidade, dificultando a recuperação e ressocialização do usuário, o que resulta em impactos para a sociedade além dos normais às outras espécies de droga, a fração de diminuição da pena será de 1/3 (um terço).

Destaco, por fim que, para não incorrer em bis in idem, as circunstâncias da quantidade e natureza da droga não serão utilizadas na primeira fase da dosimetria, já que foram consideradas para fixação de patamar menos elevado da causa de diminuição de pena (STF. Plenário. ARE 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2014 – Repercussão Geral).

Quanto à causa de aumento de pena alegada pelo Ministério Público, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, nos casos de envolvimento de menor na prática dos delitos dos artigos 33 e a 37 da Lei de Drogas, deve incidir a causa de aumento do artigo 40, VI, do mesmo diploma legal, em razão do princípio da especialidade, e não o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Importante frisar, ainda, que o envolvimento do menor está devidamente demonstrado pelas provas testemunhais, bem como sua presença em sede policial, bem como sua idade está comprovada documentalmente nos autos (fls. 24/25).

Ainda a respeito do envolvimento do menor, nem se diga que o menor já estaria corrompido à época dos fatos. Ocorre que, para a incidência do crime autônomo do artigo 244-B do ECA ou para a incidência da mencionada causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de drogas, é necessário tão somente o envolvimento da criança ou do adolescente.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula 500 do STJ, que dispõe que "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

O conjunto probatório é seguro e convincente, a despeito da revelia do réu, corroborada pela narrativa coesa policiais que participaram de sua prisão, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no

artigo 68 do Código Penal.

Ao delito descrito pelo artigo 33, caput da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Na primeira fase da dosimetria, devem ser consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal e, conforme o artigo 42 da Lei 11.343/06, devem ser consideradas com preponderância a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, verifica-se que nenhuma das circunstâncias elencadas têm o condão de agravar a pena base do réu, razão pela qual, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, atenuantes genéricas não incidem, dado não terem o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, em observância ao princípio da legalidade (Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça).

Desta forma, fica mantida a pena no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, aplica-se a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, no patamar de 1/6 (um sexto), pela prática do crime ter envolvido adolescente. Conforme já mencionado na fundamentação alhures, quanto ao privilégio, incidirá redução no patamar de 1/3 (um terço).

Ficam as penas definitivas, portanto, em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

O regime inicial de cumprimento de pena será ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Não se aplica o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, já que fixado regime mais favorável.

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensão vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pela Resolução número 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, não se afigurando a medida socialmente recomendável, especialmente considerando-se a natureza e diversidade das drogas apreendidas (art. 44, inciso III, e § 3º, CP).

Tampouco faz jus ao sursis (artigo 77, caput, Código Penal), pela quantidade de pena aplicada.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu FELIPE GERVASIO DA SILVA, por infração ao artigo 33, caput e §4º, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O réu encontra-se solto e, diante do desate processual, faculto direito a recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) proceda-se à transferência do dinheiro apreendido a fls. 18 ao Funad, decretado seu perdimento em favor da União; d) oficie-se para destruição das amostras guardadas para contraprova (artigo 72, da

Lei 11.343/06); e) oficie-se ao TRE para fins do disposto no artigo 15, III da CF/88, f) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil.
Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.
Custas na forma da lei.
Publicada pela liberação nos autos digitais.
Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.
São Paulo, 21 de novembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA